



서울고등법원 2024. 2. 1. 선고 2022누36102 판결

(행정 7부: 판사 이규홍, 이지영, 김슬기)

● 아래 내용은 취재의 편의를 위하여 공보관이 요약한 것으로 정확한 내용은 판결문을 확인하시기 바랍니다.

1. 주문

1. 피고가 2021. 9. 23. 의결 제2021-237호로 원고에게 한 [별지 1] 기재 각 시정명령, 통지명령 및 과징금납부명령을 모두 취소한다.
2. 소송비용은 피고가 부담한다.

[별지 1]

피고의 처분

1. 원고는 납품업자에게 원고의 경쟁사 온라인몰의 판매가격 인상을 요구하고 원고의 판매가격이 다른 경쟁 온라인몰의 판매가격보다 높게 판매되지 않도록 지속적으로 관리하고 유도하는 방법으로 거래상대방의 경영활동을 부당하게 간섭하는 행위를 다시 하여서는 아니 된다.
2. 원고는 납품업자의 의사에 반하여 해당 납품업자의 상품에 관한 광고를 하게 하는 행위를 다시 하여서는 아니 된다.
3. 원고는 판매촉진행사를 실시하면서 납품업자에게 판매촉진행사에 소요되는 비용의 100분의 50을 초과하여 부담하게 하는 행위를 다시 하여서는 아니 된다.
4. 원고는 납품업자와 판매장려금의 액수, 지급시기 및 지급횟수, 변경사유 및 변경기준 등 판매장려금 지급에 관한 약정 사항을 연간거래 기본계약의 내용으로 약정하지 아니하고 납품업자로부터 판매장려금을 받는 행위를 다시 하여서는 아니 된다.
5. 원고는 이 시정명령을 받은 날부터 30일 이내에 위 1. 내지 4.의 행위를 함으로써 「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」 및 「대규모유통업에서의 거래 공정화에 관한 법률」을 위반하였다는 이유로 공정거래위원회로부터 시정명령을 받았다는 사실을 <별지> 기재의 문안대로 원고가 관리하는 납품업자 전용 사이트에 공지함과 동시에 원고와 거래하는 모든 납품업자에게 전자메일로 통지하고, 그 결과를 공정거래위원회에 보고하여야 한다. 다만, 공지 관련 게재 기간, 방식, 위치 및 글자 크기 등은 사전에 공정거래위원회와 협의를 거친 것이어야 한다.
6. 원고는 다음 각 호에 따라 과징금을 국고에 납부하여야 한다.
 - 가. 과징금액 : 3,297,000,000원
 - 나. 납부기한 : 과징금 납부고지서에 명시된 납부기한(60일) 이내
 - 다. 납부장소 : 한국은행 국고수납 대리점 또는 우체국 (끝)



2. 사안의 개요

	시정명령(금지명령)	통지명령	과징금납부명령
판매가격인상 요구행위	○	○	1,360,000,000원
광고게재 요구행위	○	○	160,000,000원
판매촉진비용 부담전가행위	○	○	1,277,000,000원
판매장려금 수취행위	○	○	500,000,000원
			합계 3,297,000,000원

3. 판단 요지

가. 원고의 거래상 지위

1) 법리

▣ 공정거래법상 ‘거래상 지위’와 대규모유통업법상 ‘거래상 우월적 지위’의 이동(異同)

- 공정거래법에서는 ‘거래상 지위’라고 하고, 대규모유통업법에서는 ‘거래상 우월적 지위’라고 하는바, 양자가 같은 것인지 다른 것인지 문제됨
- 다음과 같은 사정 등을 종합하면, 양자는 결국 같은 의미라고 보아야 할 것임
 - ① 공정거래법의 입법연혁을 볼 때 ‘거래상 우월적 지위’라는 표현은 결국 ‘거래상 지위’를 의미하는 것으로 보이고, 판례 역시 거래상 우월적 지위와 거래상 지위를 달리 보고 있지 않은 점
 - ② 판례의 거래상 지위에 관한 설시 중 후자, 즉 ‘적어도 상대방의 거래활동에 상당한 영향을 미칠 수 있는 지위’는 전자, 즉 ‘상대적으로 우월한 지위’를 풀어 설명하거나 달리 표현한 것으로 볼 수 있는 점
 - ③ 대규모유통업법이 공정거래법과 달리 ‘거래상 우월적 지위’라는 표현을 사용한 것과 관련하여 명확한 입법취지는 알려진 것이 없는바, 이를 그 지위 요건을 강



화하기 위한 취지라고 단정하기 어려운 점

- ④ 설령 대규모유통업법의 적용범위를 제한할 필요가 있다 하더라도, 이를 위하여 반드시 거래상 우월적 지위를 거래상 지위보다 가중된 요건으로 새길 필요는 없다 할 것인바, 양자를 차별화하는 것은 오히려 학계와 실무계에 불필요한 혼란을 야기할 우려가 있는 점

■ 증명책임의 소재

- 공정거래법상 거래상 지위의 존재에 관한 증명책임은 공정거래위원회에게 있다는 점에 별다른 의문이 없으나, 대규모유통업법상 거래상 우월적 지위의 존부에 관하여도 공정거래위원회가 증명책임을 부담하는 것인지 의문이 제기될 수 있음
- 다음과 같은 사정 등을 종합적으로 고려하면, 대규모유통업법상 거래상 우월적 지위에 관하여도 공정거래위원회가 그 증명책임을 부담한다고 보는 것이 타당함
 - ① 앞서 본 바와 같이 대규모유통업법은 공정거래법상 거래상 지위 남용의 특칙이고, 대규모유통업법상 거래상 우월적 지위는 결국 공정거래법상 거래상 지위를 의미하는바, 즉 거래상 우월적 지위가 인정되지 않는 대규모유통업자에게 대규모유통업법을 적용할 수 없는 것은 당연하고, 대규모유통업법의 적용제외 규정은 이를 확인하는 의미를 가진다고 보아야 할 것인 점
 - ② 만일 거래상 우월적 지위에 관한 증명책임이 대규모유통업자에게 있다고 본다면, 대규모유통업자로서는 ‘거래상 우월적 지위가 없다’는 점을 증명하여야 하는데, 위와 같은 ‘부존재’의 증명을 요구하는 것은 특별한 사정이 없는 한 그리 적절하지 않고, 이는 유통업의 특성을 고려하더라도 다르지 않은 점
 - ③ 한편 위와 같이 증명책임을 대규모유통업자에게 돌릴 경우, 공정거래법에 비하여 매우 강력한 제재사유와 제재수준을 규정하고 있는 대규모유통업법의 적용범위가 지나치게 확장되고, 이로써 대규모유통업에서의 공정한 거래질서 확립을 넘어 납품업자를 과도하게 보호하고, 오히려 대규모유통업에 관한 경쟁과 혁신을 저해하는 결과를 초래할 우려도 있는 점

■ 소결

- 비록 대규모유통업법이 공정거래법과 달리 ‘거래상 우월적 지위’라는 표현을 사용하고, ‘거래상 우월적 지위가 인정되지 않는 경우 적용을 제외한다’는 규정을 두고 있으나, 거래상 우월적 지위는 결국 거래상 지위와 같은 의미이고, 그에 관한



증명책임 역시 공정거래위원회가 부담한다고 보아야 함

- 이하 이러한 관점을 전제로 봄(이하 특별한 사정이 없는 한 ‘거래상 우월적 지위’라는 표현은 사용하지 않고, 단순히 ‘거래상 지위’라고만 표현하기로 함)

2) 구체적인 판단

- 아래와 같은 사정에 비추어 보면, 피고가 주장하는 사정과 제출한 증거들만으로는 원고가 이 사건 8개 독과점 제조업체들에 대하여도 거래상 지위를 가진다고 보기 어려움

- 거래상 지위의 의미와 판단기준

- 공정거래법에서 거래상 지위 남용을 규제하고 있는 것은, 현실의 거래관계에서 경제력에 차이가 있는 거래주체 간에도 상호 대등한 지위에서 같은 법이 보장하고자 하는 공정한 거래를 할 수 있게 하기 위한 것임(대법원 2006. 9. 8. 선고 2003두 7859 판결 등 참조). 위와 같은 거래상 지위란 결국 우월한 협상력, 즉 거래상대방을 그 의사에 반하여 착취할 수 있는 힘을 의미함
- 그런데 거래당사자 사이에 모든 조건이 동등한 경우는 오히려 이례적이므로, 거래상 지위는 민법이 예상하고 있는 통상적인 협상력의 차이와 비교할 때 훨씬 엄격한 기준으로 판단되어야 할 것인바, 사적 자치와 계약 자유의 원칙에도 불구하고 행정권의 고권적 개입을 정당화할 수 있을 정도로 거래당사자 사이에 현저한 협상력의 차이가 있을 것이 필요함. 즉 ‘당사자가 처하고 있는 시장의 상황, 당사자 간의 전체적 사업능력의 격차, 거래의 대상인 상품의 특성’ 등 제반 사정을 고려할 때(대법원 2011. 5. 13. 선고 2009두24108 판결 등 참조) 거래의존도가 높고 대체거래선이 없어 거래상대방이 행위자에게 사실상 종속되어 있다고 인정되지 않은 이상, 행위자가 거래상대방에 비하여 사업능력 면에서 다소 우위를 점하고 있다는 사정만으로 쉽사리 거래상 지위를 인정하여서는 안 됨
- 한편 이러한 거래상 지위는 시장지배적 지위와 엄연히 구별되는 개념임. 시장지배적 지위는 경쟁사업자들과의 관계를 전제로 한 절대적 지위인 반면, 거래상 지위는 거래상대방과의 관계를 전제로 한 상대적 지위임. 전자는 경쟁사업자들에 따라 달라질 수 없다는 의미에서 일반적인 데 반하여, 후자는 거래상대방에 따라 달라질 수 있다는 점에서 개별적임. 물론 시장지배적 지위와 거래상 지위가 전혀 무관하다고 할 것은 아니고, 행위자가 관련시장에서 시장지배적 지위를 가지는 사업자라면

특별한 사정이 없는 한 그 거래상대방에 대하여도 거래상 지위를 가질 가능성이 큼. 그러나 만일 그 거래상대방 또한 자신의 관련시장에서 시장지배적 지위를 가지고 있거나, 적어도 상당한 규모 내지 자금력, 영업력 등 사업능력을 가지고 있어 타방 당사자에게 쉽게 종속될 수 있는 상황이 아니라면, 과연 행위자가 위와 같은 거래상대방에 대하여도 거래상 지위를 가지는지는 보다 신중하게 판단하여야 함

- 이러한 사정은 대규모유통업법에 있어서도 기본적으로 마찬가지임. 대규모유통업법은 공정거래법이 금지하는 거래상 지위 남용을 구체화한 위 법률의 특칙으로서 납품업체 등이 대규모유통업자와 상호 대등한 지위에서 공정한 거래를 할 수 있도록 보장하는 데에 그 취지가 있음(대법원 2021. 11. 25. 선고 2018두65071 판결 등 참조).
- 그런데 대규모유통업법은 공정거래법에 비하여 그 규제수준을 대폭 강화하고 있으면서도, 일정한 규모 내지 매출액이 인정될 경우 즉시 대규모유통업자로 의제하고, 하도급거래 공정화에 관한 법률, 가맹사업거래의 공정화에 관한 법률, 대리점거래의 공정화에 관한 법률 등과 달리 ‘행위주체의 대기업성’이나 ‘거래상대방의 중소기업성’ 또는 ‘행위주체와 거래상대방 사이의 상당한 경제력 차이 내지 본질적 협상력 차이’ 등을 적용요건으로 명시하지 않은 채, 오히려 ‘거래상 지위가 인정되지 않는 경우’ 적용을 제외하도록 규정하고 있는바, 자칫 법상 대규모유통업자에 해당하기만 하면 그 자체로 모든 납품업자들에 대하여 거래상 지위를 가진다는 결론에 이르게 될 가능성이 있음
- 따라서 대규모유통업자의 거래상 지위를 인정함에 있어서는 더욱 신중할 필요가 있다 할 것인바, ‘유통시장의 구조, 소비자의 소비실태, 대규모유통업자와 납품업자 사이의 사업능력의 격차, 납품업자의 대규모유통업자에 대한 거래 의존도, 거래의 대상이 되는 상품의 특성 및 공정거래법상 기업집단이나 하나의 대규모유통업자가 운영하는 유통업태의 범위’ 등을 종합적으로 고려하고(대규모유통업법 제3조 제2항), 과연 ‘해당 대규모유통업자가 특정 납품업자에 대하여 우월한 협상력을 보유함으로써 그 납품업자를 부당하게 착취할 우려가 있는지’의 관점에 유념하여 거래상 지위의 존부를 판단하여야 함

● 다수의 거래상대방에 대한 거래상 지위의 증명방법

- 거래상 지위는 본질적으로 개별적·상대적인 것이므로, 대규모유통업자가 납품업자들에게 거래상 지위를 가지는지 여부는 납품업자 별로 각각 개별적·구체적으로

판단하여야 함

- 이 사건의 경우, 원고는 8개 독과점 제조업체를 명시적으로 특정하여 적어도 그들에 대하여는 거래상 지위를 가지지 않는다고 반복적으로 주장하면서 나름의 근거들을 제시하고 있음에도, 피고는 원고의 일반적 시장지위 내지 유통업의 일반적 특성 등만을 근거로 제시하고 있을 뿐, 위 8개 독과점 제조업체들에 관한 개별적·구체적인 증거는 전혀 제출하지 못하고 있는바, 결국 원고가 위 8개 독과점 제조업체들에 대하여도 거래상 지위를 가진다고 인정하기는 어려움
- 이에 관하여 피고는, 모든 납품업자들에 대하여 개별적·구체적 조사를 하는 것은 현실적으로 불가능하다고 주장하나, 그러한 사정만으로 거래상 지위에 관한 증명의 필요가 없어지거나 증명의 정도가 낮아진다고 볼 수 없음

● 필수상품과 거래상 지위

- 전통적인 오프라인 종합소매유통, 즉 대형마트, 백화점, 편의점, 가전양판점 등 오프라인 종합소매유통과 달리, 최근 급격히 성장하고 있는 온라인 종합소매유통의 경우는 지리적 한계가 없고, 손쉽게 다른 온라인 쇼핑몰을 방문할 수 있으며, 필요하다면 언제든지 특정 소량의 상품을 구매할 수 있고, 상품의 가격이나 품질의 비교 역시 용이하므로, 소비자는 자신이 원하는 바로 그 상품을 찾아 다수의 온라인 쇼핑몰들 사이에서 기꺼이 구매를 전환하고, 특정 온라인 쇼핑몰을 선호한다 하더라도 반드시 그곳에서 필요 물품들을 일괄하여 구매하지도 않음
- 이에 불특정 다수인 소비자들의 선호와 방문을 유지하고자 하는 온라인 유통업자로서는 가능한 한 다양한 상품 구색을 갖추 수밖에 없고, 특히 해당 품목에서 널리 알려진 전형적인 상품이나 구매량이 많은 필수상품은 반드시 구비하고 있는 것이 필요하게 되는데, 만일 기존에 사용하던 온라인 쇼핑몰에서 원하는 상품을 구매하지 못하는 경험이 반복된다면, 소비자들은 가격이나 서비스, 배송 등에 큰 차이가 없는 한 그 상품들을 구매할 수 있는 다른 온라인 쇼핑몰로 이동하게 될 것임
- 한편 상당한 규모와 시설을 갖춘 물리적 매장이 필수적인 오프라인 종합소매유통에 비하여 상대적으로 그러한 필요가 적은 온라인 종합소매유통의 경우 그 진입이 비교적 용이하고, 이에 실제로 보다 많은 사업자들이 존재하고 있으며, 각 사업자별로 별다른 지역적 분할이 존재하지도 않는바, 특별한 사정이 없는 한 납품업자들 입장에서 대체거래선을 찾는 것도 그리 어려운 일이 아닐 수 있음
- 이러한 상황에서는 유통업자가 납품업자에 대하여 거래상 지위를 가질 개연성은

상대적으로 떨어지고, 오히려 만일 납품업자가 필수상품을 보유하고 있다면 설령 대규모유통업자라 하더라도 그 납품업자와의 관계에서는 거래상 열위에 처하게 될 가능성이 있음

- 요컨대, 어디까지나 개별적·구체적인 판단이 필요한 문제이기는 하지만, 오프라인 종합소매유통에서는 설령 필수상품을 보유한 납품업자라 하더라도 유통업자가 그에 대하여 거래상 지위를 가질 개연성이 큰 반면, 온라인 종합소매유통에서는 대규모유통업자라 하더라도 필수상품을 보유한 납품업자에게 거래상 열위에 있을 가능성이 있음
- 이 사건의 경우 8개 독과점 제조업체들은 해당 품목에 관하여 인지도가 높은 전형적인 상품 내지 선호도가 높은 필수상품을 납품하고 있는바, 이러한 사정에 비추어 보면 단지 원고가 모바일 유통의 강자로서 8개 독과점 제조업체들에게 상당한 사업상 의미를 가진다는 사정만으로 원고가 위 8개 독과점 제조업체들에 대하여도 당연히 거래상 지위를 가진다고 보기는 어렵다 할 것임

● 원고와 8개 독과점 제조업체의 사업능력

- 만일 어떤 사업자가 관련시장에서 시장지배적 지위를 가지고 있다면, 특히 그 관련 시장이 유통시장이고, 그 사업자가 대규모유통업자에 해당한다면, 해당 대규모유통업자는 납품업자들에 대하여 거래상 지위를 가질 개연성이 큰 점은 앞서 본 바와 같으나, 거래상 지위의 본질적 개별성·상대성을 감안할 때, 위와 같은 경우라 하더라도 만일 그 납품업자 역시 자신의 관련시장에서 시장지배적 지위를 가지고 있거나 적어도 상당한 규모 내지 사업능력을 갖추고 있다면 해당 대규모유통업자가 그 납품업자에 대하여도 거래상 지위를 가진다고 인정하기 위하여는 신중한 검토가 필요한 점 역시 앞서 본 바와 같다. 즉 만일 대규모유통업자와 납품업자 쌍방이 모두 상당한 사업능력을 갖추고 있는 경우라면, 그중 어느 쪽의 사업능력이 상대적으로 더 큰지, 양자의 차이가 착취가 발생할 수 있을 정도로 현저한지를 살펴보는 것이 중요함
- 거래상 지위의 존부는 현재 시점이 아니라 문제된 행위 당시를 기준으로 판단하여야 할 것인바, 이 사건 위반행위는 2017년경부터 2020년경까지에 걸쳐 있으므로, 위 기간 동안 쌍방의 시장점유율을 보면, 원고의 사업능력이 8개 독과점 납품업체들의 사업능력보다 더 우월하다고 단정하기 어렵고, 설령 원고의 사업능력이 더 우월하다고 보더라도 적어도 그 사업능력의 격차가 원고가 8개 독과점 제조업체들을

착취할 수 있는 정도라고 보기는 어렵다 할 것임

● 8개 독과점 제조업체의 원고에 대한 종속성

- 쌍방의 타방에 대한 거래의존도와 대체거래선의 유무를 보면, 피고가 제출하는 증거들만으로는 8개 독과점 제조업체들이 원고에게 종속되어 있다고 보기에 부족하고, 달리 이를 인정할 증거가 없음(물론 이러한 판단이 오히려 원고가 8개 독과점 제조업체들에게 종속되어 있다는 취지는 아님)
- 이와 관련하여 피고는, '납품업자라면 누구나 매출 증진을 위하여 온라인 유통망을 통한 거래를 희망할 수밖에 없고, 일단 원고와의 거래를 통하여 매출이 발생하는 이상 원고의 플랫폼을 통한 소비자와의 접촉을 계속 유지함으로써 시장에서의 점유율을 유지할 필요성이 있으며, 따라서 원고와 거래한 납품업자들로서는 원고와 계속 거래할 수밖에 없게 되는 고착화 현상이 발생하게 된다'고 주장한다. 그러나 위와 같은 논리는 온라인 유통이든 오프라인 유통이든 별반 다를 것이 없고, 오히려 해당 유통업자의 규모, 매출액 등과 상관없이 모든 유통업자들과의 관계에서 본질적으로 마찬가지라 할 것인바, 위와 같은 사정을 들어 8개 독과점 제조업체들이 원고에게 종속되어 있다고 볼 수는 없음

● 가격협상력과 거래상 지위

- 원고는 8개 독과점 제조업체들과의 거래에서 높은 납품가격으로 인하여 상당한 손실을 입고 있었던 것으로 보임. 즉 이 부분 관련 납품업자 101개 업체 중 8개 독과점 제조업체를 포함한 87개 업체의 경우 원고에 대한 납품가격이 다른 유통채널에 대한 납품가격은 물론 평균 소비자 판매가격보다도 높았던 것으로 보이는바, 원고는 해당 상품의 매입과 판매를 통하여 손실을 입고 있었던 것이 분명하고, 나머지 14개 업체의 경우를 보더라도, 해당 상품의 매입과 판매를 위한 원고의 인건비, 보관료, 물류비 등 최소한의 비용을 감안하면 원고는 위 부분의 거래에서도 손실을 입고 있었을 가능성이 큼
- 거래상 지위의 존부, 즉 우월한 협상력의 소재를 판단함에 있어 해당 거래에 관한 가격결정력은 가장 중요한 표지가 된다 할 것인바, 거래상 지위를 가진 사업자가 거래상대방과의 가격협상에서 오히려 불이익을 입는다는 것은 특별한 사정이 없는 한 상정하기 어려움. 결국 위와 같이 원고가 8개 독과점 제조업체들과의 거래에서 그 납품가격이 너무 높아 매입과 판매를 하면 할수록 손실이 발생하였다는 점은 원고가 위 8개 독과점 제조업체들에 대하여 거래상 지위를 가지고 있지 않았음을



방증하는 것임

- 이에 대하여 피고는, 대규모유통업법 제3조 제2항은 가격결정력을 거래상 지위의 판단요소로 규정하고 있지 않은바, 가격결정력이 거래상 지위 판단에 중요한 기준이 된다고 보는 것은 위 규정에 반한다고 주장함. 그러나 거래상대방을 착취하는 가장 기본적인 요소가 바로 가격이고, 위 규정은 한정적 열거규정이 아니라 주의적 예시규정으로서 설령 그에 규정되지 않은 사항이라 하더라도 거래상 지위 판단에서 제외되는 것은 아니라 할 것이므로, 피고의 위 주장은 받아들이지 않음

■ 소결론

- 원고가 8개 독과점 제조업체들에 대하여도 거래상 지위를 가진다고 볼 수 없으므로, 이 사건 처분 중 8개 독과점 제조업체들과 관련한 부분은 더 나아가 살필 필요 없이 위법함
- 이하 나머지 납품업자들에 관한 부분에 한하여 봄

나. 판매가격 인상요구행위

■ 공정거래법과 대규모유통업법의 적용관계

- 특별한 사정이 없는 한 특별법이 규정하고 있지 않은 사항에 관하여는 당연히 일반법이 적용된다 할 것인바, 대규모유통업법은 공정거래법상 거래상 지위 남용의 특칙이고(대법원 2021. 11. 25. 선고 2018두65071 판결 등 참조), 피고는 대규모유통업법에 ‘경영간섭’에 관한 규정이 없어 공정거래법상 ‘경영간섭’ 규정을 적용한 것으로 보이며, 이러한 방식의 법적용은 이미 판례에 의하여 승인된 바 있음(대법원 2020. 6. 25. 선고 2016두55896 판결 등 참조)

■ 경영간섭의 성립 여부

- 아래와 같은 사정에 비추어 보면, 피고가 제출한 증거들만으로는 원고가 이 부분 납품업자들의 거래내용을 제한함으로써 경영활동을 간섭하였다고 인정하기 어려움
- 공정거래법상 거래상 지위 남용의 하나인 ‘경영간섭’이 성립하는지 여부는 당사자가 처해 있는 시장 및 거래의 상황, 당사자 간의 전체적 사업능력의 격차, 거래의 대상인 상품 또는 용역의 특성, 그리고 해당 행위의 의도·목적·효과·영향 및 구체적인 태양, 해당 사업자의 시장에서의 우월한 지위의 정도 및 상대방이 받게

되는 불이익의 내용과 정도 등에 비추어 볼 때 정상적인 거래관행을 벗어난 것으로서 공정한 거래를 저해할 우려가 있는지 여부를 판단하여 결정하여야 함(대법원 2011. 10. 13. 선고 2010두8522 판결, 대법원 2011. 10. 13. 선고 2010두10464 판결, 대법원 2011. 10. 27. 선고 2010두8478 판결 등 참조). 그런데 거래당사자 사이에는 거래조건에 관하여 여러 가지 사항을 요청·교섭·협의를 것이 당연하고, 오히려 이를 통하여 비로소 거래의 합의에 이르는 것이므로, 설령 그 과정에서 거래상대방의 거래내용을 일부 제한하는 행위가 있었다 하더라도 그러한 사정만으로 거래상대방의 경영활동을 부당하게 간섭하였다고 단정할 수는 없다 할 것인바, 부당한 경영간섭이 성립하기 위하여는 적어도 문제된 행위가 최소한의 강제성을 가진 행위로서 정상적인 거래관행을 벗어난 것이라고 인정되어야 함

- 피고가 제출한 증거들만으로는 원고의 이 부분 행위가 단순한 제안을 넘어 최소한의 강제성을 가진 행위로서 정상적인 거래관행을 벗어난 것이라고 인정하기 어려움

■ 소결론

- 이 부분은 그 처분사유를 인정할 수 없으므로, 이에 관한 시정명령, 통지명령, 과징금납부명령은 모두 취소되어야 함

다. 광고게재 요구행위

- 피고가 제출한 증거들만으로는 원고가 이 부분 납품업자들의 의사에 반하여 광고를 하게 하였다고 인정하기 어려움
- 본 조항의 해석·적용에 있어 그 핵심은 어디까지나 강제성 여부에 있다 할 것인데, 여기서 광고를 강제한다는 것은 상대방이 광고를 하지 않을 수 없는 객관적인 상황을 만들어 내는 것을 포함하지만(구입강제에 관한 대법원 2002. 1. 25. 선고 2000두9359 판결 등 참조), 단지 광고를 하도록 촉구 또는 독려하는 것만으로는 이를 인정하기에 부족하다 할 것인바(판매목표강제에 관한 대법원 2011. 6. 9. 선고 2008두13811 판결 등 참조), 설령 광고의 구매를 요청하였다 하더라도 그것이 사실상 구매를 강제한 정도에 이르지 않고 단지 구매를 권유 또는 제안한 것에 불과한 경우에는 본 조항에서 말하는 '광고강매'가 성립한다고 볼 수 없음
- 이 부분 처분사유는 원고가 납품업자들의 의사에 반하여 자신이 실시하는 광고를



하게 하였다는 것으로서, 결국 납품업자들에게 강제로 광고를 구매하도록 하였다는 것인바, 아래와 같은 사정에 비추어 보면, 피고가 제출한 증거들만으로는 원고가 광고를 강매하였다고 인정하기에 부족함

- 나아가 이 부분의 경우, 앞서 본 판매가격 인상요구행위가 일견 부당한 요구처럼 보이는 것과 달리 광고 구매를 요청하였다고 하여 이를 그 자체로 부당하다고 보기는 어려운 이상 그 강제성을 인정하기 위하여는 보다 명백한 증거가 필요하다는 것인바, 피고가 제출한 증거들은 모두 이를 인정하기에 부족함

■ 소결론

- 이 부분은 그 처분사유를 인정할 수 없으므로, 이에 관한 시정명령, 통지명령, 과징금납부명령은 모두 취소되어야 함

라. 광고게재 요구행위

- 피고가 제출한 증거들만으로는 원고가 이 부분 납품업자들의 의사에 반하여 광고를 하게 하였다고 인정하기 어려움
- 대규모유통업자는 정당한 사유 없이 '납품업자의 의사에 반하여' 해당 납품업자의 상품에 관한 광고를 하게 하여서는 안 된다(대규모유통업법 제17조 제6호).
 - 본 조항의 해석·적용에 있어 그 핵심은 어디까지나 강제성 여부에 있다 할 것인데, 여기서 광고를 강제한다는 것은 상대방이 광고를 하지 않을 수 없는 객관적인 상황을 만들어 내는 것을 포함하지만(구입강제에 관한 대법원 2002. 1. 25. 선고 2000두9359 판결 등 참조), 단지 광고를 하도록 촉구 또는 독려하는 것만으로는 이를 인정하기에 부족하다 할 것인바(판매목표강제에 관한 대법원 2011. 6. 9. 선고 2008두13811 판결 등 참조), 설령 광고의 구매를 요청하였다 하더라도 그것이 사실상 구매를 강제한 정도에 이르지 않고 단지 구매를 권유 또는 제안한 것에 불과한 경우에는 본 조항에서 말하는 '광고강매'가 성립한다고 볼 수 없음
- 이 부분 처분사유는 원고가 납품업자들의 의사에 반하여 자신이 실시하는 광고를 하게 하였다는 것으로서, 결국 납품업자들에게 강제로 광고를 구매하도록 하였다는 것인바, 피고가 제출한 증거들만으로는 원고가 광고를 강매하였다고 인정하기에 부족함



- 나아가 이 부분의 경우, 앞서 본 판매가격 인상요구행위가 일견 부당한 요구처럼 보이는 것과 달리 광고 구매를 요청하였다고 하여 이를 그 자체로 부당하다고 보기는 어려운 이상 그 강제성을 인정하기 위하여는 보다 명백한 증거가 필요할 것인바, 피고가 제출한 증거들은 모두 이를 인정하기에 부족함

■ 소결론

- 이 부분은 그 처분사유를 인정할 수 없으므로, 이에 관한 시정명령, 통지명령, 과징금납부명령은 모두 취소되어야 함

마. 판매촉진비용 부담전가행위

1) 납품업자 분담비율 50% 제한의 위반 여부

- 피고가 주장하는 사정과 제출한 증거들만으로는 원고 스스로 범위반을 인정하는 ‘2019년 베이비페어 1차’ 부분 외에 나머지 부분에 관하여도 원고가 납품업자들에게 50%를 초과하는 판매촉진비용을 부담시켰다고 인정하기는 어려움
- 여기서 위 분담비율 산정의 전제가 되는 판매촉진비용의 범위가 문제됨
 - 이 사건의 경우, 만일 피고의 주장과 같이 ‘사전 서면약정에 기재된 비용’ 만이 이에 해당한다면, 사전 서면약정에 기재된 비용은 쿠폰비용밖에 없으므로, 이 사건 납품업자의 분담비율은 100%가 되어 50%를 초과하는 것이 명백함. 그러나 만일 원고의 주장과 같이 ‘실제로 소요된 전체 판매촉진비용’ 이 모두 포함된다면, 원고가 부담하였다고 주장하는 ‘광고비’ 등의 실제 부담 여부 및 그 액수에 따라 이 사건 납품업자의 분담비율은 50%를 초과하지 않을 가능성이 있음
 - 그러므로 보건대, 대규모유통업법 제11조 제1항에 의하면 판매촉진비용이란 ‘판매촉진행사에 소요되는 비용’ 일체를 의미하고, 이는 제2항 이하에서도 모두 마찬가지이다. 즉 대규모유통업법 제11조는 판매촉진비용을 정의하면서 그것이 ‘사전에 서면으로 약정되어 있을 것’ 을 요구하고 있지 않은바(이와 달리 다음 항목에서 보는 ‘판매장려금’ 의 경우 대규모유통업법 제2조 제9호는 반드시 ‘연간거래 기본계약’ 으로 약정할 것을 요구하고 있음), 제2항이 규정하고 있는 사전 서면약정은 판매촉진비용을 납품업자에게 부담시키기 위한 요건일 뿐임
 - 따라서 특별한 사정이 없는 한 제3, 4항에 의한 분담비율 제한의 전제가 되는 판매



촉진비용 역시 ‘판매촉진행사에 소요되는 비용’ 일 것이 요구될 뿐, ‘사전 서면 약정에 기재된 비용’에 한정된다고 볼 수 없음

- 대규모유통업법 제11조에서 말하는 판매촉진비용은 판매촉진행사에 소요되는 비용 일체를 의미하고, 이는 제4항의 해석에 있어서도 마찬가지라 할 것인바, 납품업자의 판매촉진비용 부담비율이 50%를 초과하는지 여부를 판단함에 있어 그 산정의 기준이 되는 판매촉진비용에는 사전 서면약정에 기재된 비용은 물론 추후 추가된 비용 또한 그것이 판매촉진행사에 소요되었다는 것이 인정되고, 나아가 그 비용을 대규모유통업자가 부담한 사실이 인정되는 한 모두 포함되어야 함
- 결국 이 부분 처분사유 중 원고 스스로 범위반을 인정하는 부분(2019년 베이비패어 1차)을 제외한 나머지 부분은 인정하기 어려움

2) 처분의 취소 여부

- 이상 살펴본 바와 같이 이 부분은 그 처분사유 중 일부만 인정되는바, 이러한 경우 이에 관한 시정명령, 통지명령 및 과징금납부명령의 취소 여부 내지 그 범위가 문제됨
- 우선 과징금납부명령의 경우, 처분을 할 것인지 여부와 처분의 정도에 관하여 재량이 인정되는 과징금납부명령에 대하여 그 명령이 재량권을 일탈하였을 경우 법원으로서도 재량권의 일탈 여부만 판단할 수 있을 뿐이지 재량권의 범위 내에서 어느 정도가 적정한 것인지에 관하여는 판단할 수 없어 그 전부를 취소할 수밖에 없고, 법원이 적정하다고 인정되는 부분을 초과한 부분만 취소할 수는 없는 것이므로(대법원 2009. 6. 23. 선고 2007두18062 판결 등 참조), 이 부분 과징금납부명령은 전부 취소되어야 함
- 한편 시정명령, 통지명령의 경우, 피고는 대규모유통업법을 위반한 대규모유통업자에 대하여 그 위반행위를 시정하기 위하여 필요하다고 인정되는 제반 조치를 할 수 있고, 이러한 시정의 필요성 및 시정에 필요한 조치의 내용에 관하여는 피고에게 그 판단에 관한 재량이 인정되며, 그 기초가 된 위반행위의 일부가 인정되지 않는다고 하더라도 나머지 위반행위가 인정되는 이상 그에 관한 시정명령, 통지명령은 여전히 적법하다고 볼 수 있는 것이 원칙임(대법원 2018. 10. 12. 선고 2016두30897 판결, 대법원 2022. 4. 28. 선고 2019두36001 판결 등 참조)
 - 그러나 피고는 그 위법의 정도, 위반행위의 파급효과, 행위자의 시정의사 등 제반

사정을 고려하여 반드시 시정명령, 통지명령 등의 조치가 아니라 경고 내지 시정권고 등의 조치를 할 수도 있고(공정거래위원회 회의 운영 및 사건절차 등에 관한 규칙 제57조, 제58조 및 [별표] 경고의 기준 등 참조), 어느 경우에도 비례와 형평의 원칙을 준수하여야 할 것인바, 위반행위의 대부분이 인정되지 않는 경우라면, 즉 당초 시정명령, 통지명령의 전제가 되었던 위반행위 중 극히 일부만이 인정되는 경우라면, 예외적으로 그 시정명령, 통지명령을 취소함으로써 피고로 하여금 다시 재량권을 행사하여 비례와 형평의 원칙에 맞는 적절한 조치를 하도록 함이 타당함

- 이 사건의 경우, 피고는 당초 원고가 ‘11차례의 판매촉진행사에서 납품업자들에게 판매촉진비용 2,851,483,525원을 부당하게 전가하였다’고 보아 시정명령, 통지명령을 하였는데, 적어도 현재로서는 그 중 ‘1차례의 판매촉진행사(2019년 베이비페어 1차)에서 납품업자들에게 판매촉진비용 50,175,320원을 부당하게 전가하였다’는 부분만 인정되어 그 인정비율이 약 1.7%에 불과한바, 이러한 상황이라면 이 부분 시정명령, 통지명령 또한 전부 취소하는 것이 타당함

바. 판매장려금 수취행위

- 원고가 연간거래 기본계약 없이 판매장려금 명목의 금원을 받았다 하더라도, 이를 들어 대규모유통업법 제15조 제2항 위반이라고 볼 수는 없고, 달리 원고가 대규모유통업법 제15조 제2항을 위반하였음을 인정할 근거가 없음
- 여기서 만일 대규모유통업자가 연간거래 기본계약 없이 판매장려금 명목으로 경제적 이익을 받은 경우 대규모유통업법 제15조 제2항 위반이 성립하는지 문제됨
 - 대규모유통업법 제2조 제9호에 의하면 ‘판매장려금’이란 “명칭에 상관없이 직매입거래에서 상품의 판매촉진을 위하여 연간거래 기본계약에 명시된 조건에 따라 납품업자가 대규모유통업자에게 지급하는 경제적 이익”을 말함(이는 대규모유통업법 제2조 제8호가 ‘판매촉진행사’를 정의하면서 “명칭이나 형식에 상관없이”라고 규정하고 있는 것과 대비된다)
 - 즉 직매입거래에서 상품의 판매촉진을 위하여 납품업자가 대규모유통업자에게 지급하는 경제적 이익의 경우, 그 ‘명칭’은 어떠하더라도 상관없지만, 그것이 연간거래 기본계약의 ‘형식’을 갖추지 않았다면 이는 판매장려금이 아님
 - 이러한 사정에 비추어 보면, 설령 대규모유통업자가 연간거래 기본계약 없이 판매

장려금 명목의 경제적 이익을 받았다 하더라도, 이는 대규모유통업법상 판매장려금이 아니므로 제15조 제2항은 적용될 수 없고, 원칙대로 제1항이 적용되어야 함

- 한편 제15조 제2항은 대규모유통업자가 납품업자로부터 받는 경제적 이익 중 상품의 판매촉진을 위한 것은 그것이 납품업자에게도 이익이 될 수 있다는 점을 고려하여 특별히 이를 허용하고자 한 취지임
- 즉 제15조 제2항에서 연간거래 기본계약으로 판매장려금을 약정하도록 요구한 것은, ‘적법요건’으로서 이를 갖춘 경우 그것이 합리적 범위를 넘지 않는 한 별도로 정당한 사유를 주장·증명할 필요가 없음을 의미하는 것이지, ‘위법요건’으로서 이를 갖추지 않은 경우 정당한 사유를 주장·증명할 기회조차 박탈한 채 오히려 다른 경제적 이익보다 더 가혹하게 규제하려는 취지가 아니라 할 것이다. 이에 비추어 보더라도, 연간거래 기본계약 없이 받은 판매장려금이라는 이유만으로 제15조 제2항 위반이 성립한다고 볼 수는 없는바, 이러한 해석이 유통업의 특성과 거래계의 현실에도 부합함

● 요컨대, 원고가 연간거래 기본계약 없이 판매장려금 명목의 금원을 받았다 하더라도, 이에 대하여는 대규모유통업법 제15조 제2항이 적용될 수 없고, 제1항이 적용되어야 할 것인바, 이를 그 자체로 제15조 제2항 위반이라고 본 이 부분 처분은 위법함

● 소결론

- 이 부분은 그 처분사유를 인정할 수 없으므로, 이에 관한 시정명령, 통지명령, 과징금납부명령은 모두 취소되어야 함